

1500166-15.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Gisele de Castro Catapano

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... III DO ART. 105 DA CF/88). CRIME DE ROUBO: MOMENTO DE CONSUMAÇÃO. É firme a jurisprudência desta colenda Corte de que o delito de roubo se consuma no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel subtraída mediante grave ameaça ou violência. Noutros termos: é de se considerar consumado o roubo, quando o agente, cessada a violência ou a grave ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

1ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Jardim das Flores, cep 06110-100, Osasco, SP

Fone: (11) 2838-7557 - E-mail: osasco1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Processo Digital 1500166-15.2022.8.26.0542 | Sentença | lauda 0 de 0  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500166-15.2022.8.26.0542

Controle: 2022/000121

Autor:

Justiça Pública

Acusado:

RODRIGO EULALIO SABINO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gisele de Castro Catapano

Vistos,

RODRIGO EULÁLIO SABINO, qualificado nos autos, foi denunciado por incurso nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal, porque, em 15 de janeiro de 2022, por volta das 19h30min, na Rua Agostinho Navarro, 560, Conceição, nesta Cidade e Comarca de Osasco-SP, subtraiu para si, mediante grave ameaça, exercida com simulação de emprego de arma de fogo, em face de Graciana, o automóvel Chery, EZE3D51, pertencente a Marcelo.

Apurou-se que Marcelo estacionou o veículo em frente a sua residência, a fim de pegar cartão bancário, ao passo que a namorada dele, Graciana, permaneceu no automotor, este com a chave na ignição.

Ao avistar Graciana no interior do automotor, Rodrigo Eulálio se aproximou, simulou portar arma de fogo sob a blusa e anunciou o assalto, exigindo a entrega do aparelho telefone celular dela.

Suspeitando de que Rodrigo Eulálio não estivesse de fato armado, Graciana não entregou o aparelho telefone celular e, assustada, saiu do automóvel.

Ato contínuo, Rodrigo Eulálio subtraiu o veículo, evadindo-se na condução deste. Informados acerca das características físicas do agente e das características do automóvel subtraído, policiais militares, em patrulhamento, avistaram Rodrigo Eulálio nas imediações da Via Transversal Sul.

Instada a comparecer ao Quinto D.P. Local, Graciana reconheceu Rodrigo Eulálio, sem sombra de dúvidas, como o autor do delito que lhe vitimara.

A denúncia foi recebida em 19 de janeiro de 2022 (fls. 74/76) e citado Rodrigo Eulálio (fls. 80). Sobreveio a resposta escrita (fls. 84) e, não havendo causas de sumária absolvição, o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 86/87).

Em instrução processual criminal foram ouvidas as vítimas (fls. 122/123) e testemunha (fls. 124). Houve desistência da oitiva de testemunha, o que foi homologado pelo Juízo (fls. 126), prosseguindo-se com o interrogatório do acusado (fls. 125).

Encerrada a instrutória, na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, nada foi requerido, sendo os debates orais convertidos em memoriais escritos (fls. 126). Em sede de memoriais escritos, a Dra. Promotora de Justiça pleiteou pela procedência da ação penal e consequente condenação de Rodrigo Eulálio nos termos da denúncia (fls. 129/133).

A Defesa, por sua vez, pediu, preliminarmente, fosse decretada a nulidade do reconhecimento extrajudicial e, no mérito, a absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso III ou VII, do Código de Processo Penal (fls. 140/162).

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

Preliminarmente, declaro a nulidade do reconhecimento pessoal na fase policial. O Superior Tribunal de Justiça, em sua mais moderna jurisprudência, estabeleceu que o reconhecimento extrajudicial, seja pessoal ou fotográfico, que não observe os ditames do artigo 226, do Código de Processo Penal, não serve de lastro para embasar a condenação, ainda que o reconhecimento seja confirmado judicialmente. “Uma reflexão aprofundada sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, leva a concluir que, com efeito, o reconhecimento (fotográfico ou presencial) efetuado pela vítima, em sede inquisitorial, não constitui evidência segura da autoria do delito, dada a falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento, quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas que podem gerar “falsas memórias”, além da influência decorrente de fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor; o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.). 5. Diante da falibilidade da memória seja da vítima seja da testemunha de um delito, tanto o reconhecimento fotográfico quanto o reconhecimento presencial de pessoas efetuado em sede inquisitorial devem seguir os procedimentos descritos no art. 226 do CPP, de maneira a assegurar a melhor acuidade possível na identificação realizada. Tendo em conta a ressalva, contida no inciso II do art. 226 do CPP, a colocação de pessoas semelhantes ao lado do suspeito será feita sempre que possível, devendo a impossibilidade ser devidamente justificada, sob pena de invalidade do ato. 6. O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial (...) 8. Tendo a autoria do delito sido estabelecida com base unicamente em questionável reconhecimento fotográfico e pessoal feito pela vítima, deve o réu ser absolvido” (Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus 652.284-SC. Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Julgamento: 27 de abril de 2021).

Ora, no caso destes autos, Graciana afirmou que os milicianos lhe disseram que antes de ir para a Delegacia deveria reconhecer o autor, o que fez, e que na Delegacia de Polícia somente Rodrigo Eulálio foi colocado para fins de

reconhecimento. Ainda, do Auto de Reconhecimento de Pessoa Positivo consta que Rodrigo Eulálio estava presente e foi imediatamente apontado, não havendo qualquer informação acerca do cumprimento das previsões do Código de Processo Penal para o ato.

Portanto, não observadas as cautelas do artigo 226, do Código de Processo Penal, uma vez que não apresentada nenhuma outra pessoa para fins de reconhecimento, esse ato extrajudicial é nulo. Observe-se, ainda, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a inobservância das regras para fins de reconhecimento na fase policial macula o reconhecimento em Juízo, eivado de preconcepção da imagem da pessoa a ser reconhecida.

"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis. 3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório. 4. O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato. 5. De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, consequentemente, de graves injustiças. 6. É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua insita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a "defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis" (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia" (art. 129, II). 7. Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não

seguir minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado. 8. Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo "processualmente admissível e válido" (Figueiredo Dias). 9. O primeiro paciente foi reconhecido por fotografia, sem nenhuma observância do procedimento legal, e não houve nenhuma outra prova produzida em seu desfavor. Ademais, as falhas e as inconsistências do suposto reconhecimento – sua altura é de 1,95 m e todos disseram que ele teria por volta de 1,70 m; estavam os assaltantes com o rosto parcialmente coberto; nada relacionado ao crime foi encontrado em seu poder e a autoridade policial nem sequer explicou como teria chegado à suspeita de que poderia ser ele um dos autores do roubo – ficam mais evidentes com as declarações de três das vítimas em juízo, ao negarem a possibilidade de reconhecimento do acusado. 10. Sob tais condições, o ato de reconhecimento do primeiro paciente deve ser declarado absolutamente nulo, com sua consequente absolvição, ante a inexistência, como se deflui da sentença, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado. 11. Quanto ao segundo paciente, teria, quando muito – conforme reconheceu o Magistrado sentenciante – emprestado o veículo usado pelos assaltantes para chegarem ao restaurante e fugirem do local do delito na posse dos objetos roubados, conduta que não pode ser tida como determinante para a prática do delito, até porque não se logrou demonstrar se efetivamente houve tal empréstimo do automóvel com a prévia ciência de seu uso ilícito por parte da dupla que cometeu o roubo. É de se lhe reconhecer, assim, a causa geral de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância). 12. Conclusões: 1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 13. Ordem concedida, para: a) com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o paciente Vânio da Silva Gazola em relação à prática do delito objeto do Processo n. 0001199-22.2019.8.24.0075, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tubarão – SC, ratificada a liminar anteriormente deferida, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso; b) reconhecer a causa geral de diminuição relativa à participação de menor importância no tocante ao paciente Igor Tártari Felácio, aplicá-la no patamar de 1/6 e, por conseguinte, reduzir a sua reprimenda para 4 anos, 5 meses e 9 dias de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Dê-se ciência da decisão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos que façam conhecer da decisão os responsáveis por cada unidade policial de investigação" (Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus 598.886-SC. Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz. Julgamento: 13 de abril de 2021).

Assim sendo, com fulcro no artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal DECLARO NULA a PROVA consistente em RECONHECIMENTO PESSOAL EXTRAJUDICIAL e, por derivação, a PROVA do RECONHECIMENTO JUDICIAL (Supremo Tribunal Federal. R.H.C. 90.376. Relator: Ministro Celso de Mello. Julgamento: 2 de abril de 2007).

No mais, a materialidade delitiva consubstancia-se em auto de prisão em flagrante delito (fls. 1), boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 7/10), auto de exibição, apreensão, avaliação e entrega (fls. 11), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 12), bem como pelos testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório (fls. 122/124) e, especialmente, pela confissão judicial de autoria de (fls. 125). Perante a D. Autoridade Policial, Rodrigo Eulálio se reservou no direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 6).

Em Juízo, confessou a prática delitiva. Declarou que não estava armado e não simulou que estivesse armado. Nesse dia tinha bebido e estava drogado. Declarou seu arrependimento (fls. 150).

Infere-se que a confissão representou idôneo liame entre a autoria e o evento perpetrado, encontrando-se corroborada pelas demais provas produzidas. Deve, pois, ser considerada sincera. Neste sentido:

"Confissão Judicial - Ausência de circunstância que evidenciem insinceridade - Suficiência - Sem margem para divagações doutrinárias ou construções hermenêuticas, a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa". (Ap. 470.903-2-SP - 8a C. - TACrim - j. 08.10.87 - Rel. Juiz Canguçu de Almeida)

A vítima Graciana relatou que estava chegando em casa e seu futuro marido desceu para pegar o cartão. Em menos de um minuto, o autor veio por trás do carro e viu que a declarante estava sozinha ali. Ele encostou no carro pelo lado do motorista, com a mão para baixo, simulando que estava armado, e mandou que entregasse o celular. Viu que ele estava abrindo a porta do carro e então desceu para entrar em casa. Ele subtraiu o carro.

O autor foi localizado. Seu marido, em seguida, acionou a polícia e mostrou as imagens do roubo ao primo, que saiu de moto. Um vizinho saiu de carro e o outra pessoa de moto. Seu primo na Transversal Sul avistou o veículo. Foi seguindo esse carro e o autor acabou estourando a embreagem do veículo. Tirou o som do carro, jogando na caçamba e saiu andando, mas foi abordado pelos policiais. Afirma que depois que os policiais o abordaram, próximo de um prédio, a declarante foi até o local. Respondeu que o autor que lhe abordou estava com camiseta cinza e emblema branco. Os policiais disseram que, antes de ir para a Delegacia, deveria reconhecer essa pessoa e, entoa, reconheceu o autor. Além da roupa fez o reconhecimento pelo rosto dele que viu no momento.

Somente o autor estava para reconhecimento. Calcula que do local do roubo até o local da prisão demora aproximadamente 10min de carro.

O autor era magro, moreno, olhos esbugalhados, cabelo cortado e cacheado (fls. 122).

A vítima Marcelo narrou que parou na frente da casa e entrou para pegar o cartão. Sua noiva ficou no veículo. Quando desceu do carro ele vinha subindo a rua. Ele deu a volta no carro e abordou sua noiva, pedindo o celular. Ela ficou parada no carro. Quando ele abriu a porta para entrar, ela saiu do carro e correu. Ele subtraiu o veículo.

Chegou a ver as feições do autor e já tinha visto o autor antes. Não pensou que ele fosse praticar o crime. Não se preocupou e entrou em casa. Quando ele fez a abordagem de sua noiva, o declarante estava ainda dentro de casa.

Não conhecia o autor, mas já tinha visto ele passando na rua. Ele é moreno, magro e tem o cabelo enrolado (fls. 123).

A testemunha Policial Militar Victor asseverou que estavam em patrulhamento na rua quando foi informado pela vítima das características do veículo roubado e do autor. Houve a informação que o veículo tinha sido avistado na Transversal Sul. Neste local encontraram o veículo e viram o autor correndo. Ele foi abordado e nada foi apreendido em suas vestes. O autor confessou o roubo e disse que estava correndo por isso. A vítima foi até o local e informalmente reconheceu o autor (fls. 124).

A autoria é, pois, indelegável.

Não há que se cogitar da existência da grave ameaça perpetrada pelo acusado. Isso porque a vítima narrou que foi abordada, sendo que o agente estava com a mão para baixo, simulando que estava armado, mandando que entregasse o aparelho telefone celular.

Tentativa, à evidência, não ocorreu. A questão do momento da consumação do crime de roubo hoje se encontra devidamente pacificada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Não é necessária a posse tranquila da coisa roubada pelo roubador, operando-se a consumação quando detém a posse, ou seja, com a retirada da coisa que estava em poder da vítima com o emprego de grave ameaça ou violência, independentemente de locupletar-se ou não depois disso. Não é, pois, necessária a posse tranquila da res, fora da esfera de vigilância do dominus.

O roubo está consumado no instante em que o agente se torna, mesmo que por pouco tempo, possuidor da res subtraída mediante grave ameaça. A rápida recuperação da coisa e a prisão dos agentes não caracteriza a tentativa (S.T.J. – R.E. 77.868 - SP - Rel. Min. Félix Fischer- J. 04.03.97- DJU 14.04.97). Tal é o entendimento, inclusive, do Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS. RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CABIMENTO (ALÍNEA "C" DO INCISO III DO ART. 105 DA CF/88). CRIME DE ROUBO: MOMENTO DE CONSUMAÇÃO. É firme a jurisprudência desta colenda Corte de que o delito de roubo se consuma no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel subtraída mediante grave ameaça ou violência. Noutros termos: é de se considerar consumado o roubo, quando o agente, cessada a violência ou a grave ameaça, inverte a posse da res furtiva. Sendo desnecessário que a posse da coisa seja mansa e pacífica. Precedentes: RE 102.490, Relator o Ministro Moreira Alves (Pleno); HC 89.958, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence (Primeira Turma); HC 89.653, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (Primeira Turma); e HC 89.619, de minha relatoria (Primeira Turma). Por outra volta, não procedem as alegações de que houve reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ) e que não ficou demonstrada a divergência de interpretação, exigida pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da CF/88. Habeas corpus indeferido” (HC 89959, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2007, DJe-087 DIVULG 23-08-2007 PUBLIC 24-08-2007 DJ 24-08-2007 PP-00070 EMENT VOL-02286-04 PP-00662 RT v. 96, n. 866, 2007, p. 565-569).

Não há qualquer viabilidade de desclassificação para o delito de furto. Do conjunto probatório amealhado aos autos, verificou-se a caracterização da grave ameaça quando da subtração. Tem-se que este elemento tipifica o crime em tela, ou seja, o roubo, cuja característica fundamental é a redução da vítima à impossibilidade de resistir pelo caráter intimidativo da grave ameaça.

Conclui-se, pois, pela procedência da ação penal, restando tipificado o delito previsto no artigo 157, caput, do Código Penal.

O acusado não agiu com intensidade dolosa anormal para os delitos da espécie que justifique a exacerbação da pena-base acima do mínimo legal, conforme permissão do artigo 59, do Código Penal.

Rodrigo Eulálio faz jus à atenuante do artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Entretanto, como é cediço, ao Magistrado não é dado transgredir os limites que a lei fixa para as penas, salvo nos casos em que tal faculdade é expressamente outorgada. Assim, inadmissível é a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, ainda quando se cuide de agente confesso judicialmente:

“Na aplicação da pena, as circunstâncias atenuantes, de consideração obrigatória, não permitem a fixação da reprimenda em parâmetros inferiores ao mínimo legal, não havendo confundi-las com as causas de diminuição de pena, que, estas sim, ensejam essa possibilidade”. (RJD 23/299)

É de se observar que a Súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça não revogou sua Súmula 231. A atenuante do artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal continua não tendo o condão de reduzir a reprimenda para abaixo do mínimo legal.

Neste sentido, inclusive, já decidiu o próprio Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA VALORADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. SÚMULA 545/STJ. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE SEM REFLEXOS NA PENA. SÚMULA

231/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - De acordo com o enunciado n. 545/STJ, "Quando a confissão for utilizada para formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal". III - In casu, a forma da confissão da paciente, para se beneficiar de tese da defesa, configura confissão qualificada, de modo que foi expressamente confirmado pelo juiz de origem que a paciente admitiu a imputação dos fatos relativos ao dia 06/01/2016. IV - Destarte, considerando a utilização da confissão para formara convicção do julgador, deve ela ser apreciada como circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria da pena. Entretanto, considerando que a pena-base da paciente foi fixada no mínimo legal, "[n]os termos da Súmula 231 desta Corte, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (AgRg no AREsp n. 623.682/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 19/10/2015). Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para reconhecer a incidência da atenuante da confissão na dosimetria, sem reflexos na pena definitiva (Súmula 231 STJ), mantidos os demais termos da condenação" (Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus 431.336-RS. Relator: Ministro Felix Fischer. Julgamento: 12 de junho, 2018. Publicação: 15 de julho, 2018).

Rodrigo Eulálio é reincidente, ex vi da informação trazida pela certidão criminal de fls. 111/114 dando conta de anterior condenação sem que tenha havido o transcurso do quinquênio depurador. Assim, nos termos do artigo 61, inciso I, do Código Penal, a reprimenda será exasperada em 1/6.

Considerando os elementos acima e os demais parâmetros contidos no artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Deixo de agravar a reprimenda pela incidência do artigo 61, inciso I, do Código Penal, compensando-o com o artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Não há outras atenuantes ou agravantes. Não há causas de aumento ou de diminuição.

À míngua de qualquer outra causa legal de alteração, torno esta definitiva.

Para o condenado determino o regime fechado para início do cumprimento da pena, coadunando-se com a natureza do crime, qual seja, roubo, praticado por reincidente, nos termos do artigo 33, § 1º, a, e § 3º, do Código Penal. Em que pese a previsão da Súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que as circunstâncias judiciais não são favoráveis, não sendo recomendável, portanto, a fixação de regime prisional mais brando. Rodrigo Eulálio, reiteradamente condenado, volta a turbar a Ordem Pública, com prática de roubo de veículo, indicando que qualquer outro regime prisional, que não o fechado, não atingirão as finalidades preventivas e repressivas.

É inaceitável a aplicação do regime mais brando. Isso porque o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa, por reincidente.

Ora, diante das circunstâncias acima evidenciadas pela grave ameaça à pessoa, a substituição da pena privativa de liberdade é incompatível.

Trata-se de delito que causa intranquilidade coletiva e de acentuada gravidade, como o roubo, praticado por reincidente. Pelas razões acima e pela quantidade de pena, sendo crime revestido de grave ameaça à pessoa, é inaplicável, ainda, a suspensão condicional da pena.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO RODRIGO EULÁLIO SABINO, qualificado nos autos, a cumprir, em regime inicial fechado, a pena de 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, com valor unitário correspondente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do delito, por incursos nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal.

A prática do crime de roubo cometido por reincidente, denota a periculosidade que é incompatível com a permanência do condenado em Sociedade, sendo necessária a segregação. A perturbação da Ordem Pública é evidente, gerando insegurança

coletiva, além de desrespeitar os direitos primordiais da vítima, assegurados constitucionalmente. Encontram-se, pois, presentes os motivos ensejadores da prisão cautelar e já elencados quando da decretação da prisão preventiva. Assim sendo, nego ao apenado o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o sentenciado ao estabelecimento prisional onde se encontra preso em razão de sentença condenatória sem direito de apelar em liberdade. Expeça-se a guia de recolhimento provisória do condenado, fazendo, oportunamente, os devidos aditamentos.

Nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, observo que Rodrigo Eulálio está custodiado por este processo-crime desde 16 de janeiro de 2022 e, diante do quantum da reprimenda aplicada, ainda não faz jus à progressão de regime e/ou detração penal, que, tão-somente, serão levadas a efeito pelo Juízo das Execuções Penais.

Por derradeiro, defiro as benesses da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98, § 1º, incisos I ao IX, do Código de Processo Civil, c.c. o artigo 1º, da Lei 1.060/50, com observância da ressalva do artigo 98, §§ 3º, 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Osasco, 21 de março de 2022.